



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

商业诋毁

定义

- 商业诋毁行为，也被称为商业诽谤行为，是指损害他人商誉、侵犯他人商誉权的行为。
- 具体而言，它是指经营者自己或利用他人，通过捏造、散布虚伪事实等不正当手段，对竞争对手的商业信誉、商品声誉进行恶意的诋毁、贬低，以削弱其市场竞争能力，并为自己谋取不正当利益的行为。
- **第十二条** 经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

商誉的特征（1）

- 抽象性
 - 商誉不仅处于一种信息状态，而且承载这种信息的载体具有多元性和不确定性。
 - 和著作、商标、专利技术、商业秘密等知识产权相比，商誉的无形性更为彻底。
- 价值性
 - 良好的商誉可以为权利人带来超过一般经营者平均利润的超额利润，因此，尽管商誉本身不具有财产的实体形态，但良好的商誉显然意味着商誉主体的竞争优势和潜在的财产利益。

商誉的特征（2）

- 相对不确定性
 - 由于评价主体与评价依据的不确定性，决定了商誉价值的不确定性。
- 依附性
 - 商誉作为一种主观的认识和评价，其必须依附于主体而存在，不能脱离商誉主体而单独成为出卖、出租、抵押、质押的客体。
- 地域性
 - 商誉的地域性与传统知识产权的地域性在含义上不一致。

传统知识产权的地域性：国家的授权
商誉的地域性：消费者的认知

商业诋毁的法律要件（1）

- 主体

- 商业诋毁的主体必须是经营者
- 非经营者呢？消费者、新闻机构

名誉权
赔偿

- 客体：

- 侵害了经营者的商誉（广义——商业评价）
- 同时也损害了竞争秩序（正确交易信息的传递

- 主观：

- 故意与过失

主观：故意或过失

- “编造、传播”的用语暗含故意或至少是过失的要求。
- 无过失的诋毁是否构成商业诋毁？
- 《巴黎公约》没有明确
- **WIPO**：虚假或者不合理的陈述不需要实际损害信誉，也不要求恶意。善意也有可能造成商誉损失。
- 解决路径：过失推定+消除影响

商业诋毁的法律要件（2）

- 客观方面

- 商业诋毁的客观方面为编造、传播**虚假信息或者误导性信息**，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
- **编造**意味着凭空编造，既包括无中生有、凭空编造全部虚伪事实的情形，也包括恶意歪曲、夸大部分事实或者虚构部分事实的情形；
- **传播**则是对编造事实加以传播。
- “**只编造未传播的不构成商业诋毁**”

编造信息的范围

- 对其他经营者及其商品、价格、雇员、信用、资格等事项

经营者个人的地位、种族、国籍、宗教信仰或者政治立场的诋毁？

看目的是什么，以及是否影响消费者的决策

编造的定性（1）

- 完全虚假的信息
 - 哇哈哈诉巨人案：巨人集团声称“哇哈哈有激素，造成婴儿早熟”
- 误导性信息（模糊、片面、部分真实）
- 太极集团诉罗氏公司案：被告通过与原告药品几个方面的比较，从而得出自己的药品更为安全的结论

360vsQQ：片面陈述真实的事实而容易引人误解

“在QQ运行过程中，会扫描您电脑里的文件，为了避免您的隐私泄露，您可以禁止QQ扫描您的文件”

编造的定性（2）

- 不恰当的表述方式：暗中诋毁
 - 彩云公司诉江西食品厂案：
- 江西食品厂发布通告，前段称“……有些作坊小厂借‘安’牌桃酥的名气，生产低档质差的桃酥，误导消费者，甚至有个别厂家利用虚假广告，欺骗消费者，严重影响了‘安’牌的声誉”，后段即称“近来不断有人来电询问：彩云食品公司是否我厂的分厂？为此江西食品厂郑重声明：彩云食品公司不是我厂分厂，更与彩云食品公司无任何关系。并提醒广大消费者买桃酥请认准著名商标‘安’牌，谨防上当！”
- 使消费者把生产低档质差产品的作坊小厂与彩云公司关联

编造的定性（3）

- 侮辱性的、主观评论性语言
 - 商业诋毁与言论自由
 - 携程诉蓝豹案：蓝豹声称携程已经姓日了，请不要再蒙骗中国人民的感情了。

“美的M I D E A 谁敢承诺？非名牌压缩机无条件退货！美的空调郑重承诺：全部采用国际知名品牌压缩机！坚决不用不出名的凌达等压缩机！”

过于针对性，最终被判属于商业诋毁

商业诋毁与商业评价自由

- 最高院：经营者有进行商业评价的言论自由，但有一定的界限。若评论给人以羞辱、藐视感觉，产生负面评价并影响竞争时，可构成商业诋毁。
- 如“两面三刀的把戏”、“卑鄙的嘴脸及阴险狡猾的别有用心”。

思考：基于个人喜好、情感、价值判断而进行的一般性或泛泛的商业评价是否构成商业诋毁？

如“中国企业要靠这样的办法，是不长久的，也是不光彩的”“进入和迈瑞相同领域的公司，都是没有前途的公司”等——迈瑞董事长在接受采访时的言论

小结

- “经营者对于他人的产品、服务或者其他经营行为并非不能评论或者批评，但评论或者批评必须由正当目的，必须客观、真实、公允和中立，不能误导公众和损人商誉。经营者为竞争目的对他人进行商业品论或者批评，尤其要善尽注意义务”

—————孔《分论》第318页

传播行为的定性

- 传播：把诋毁性信息传递到受诋毁企业之外的第三人。
- 仅仅对于受害企业的当面诋毁不属于商业诋毁。
 - 发律师函
- 第三人是复数还是单数？
 - 原则上是多数
 - 也可针对特定的单个主体，如竞争对手的交易对象，**只要诋毁信息对交易造成了误导**

第三人是否包括主管机关

- 1、向主管部门反映问题的权利应当保护
- 2、行政主管部门的特殊性，一般不会造成交易误导。
- 难点：向主管部门反映问题涉及竞争对手的交易对象
- 是否有可能构成商业诋毁？

需散布人能够控制的评价？

楼主是否要对跟帖者的内容负责？

不需要，无法控制，自己对自己的言论负责

案例：北京优孚尔公司诉上海华篷公司

- 北京优孚尔公司与上海华篷公司为同业竞争者，两家企业都对外销售橇装式加油装置。
- **2010年2月8日**，上海华篷公司向陕西省安监局反映情况，称北京优孚尔公司**2010年1月**为陕西高速延长石油公司提供的三套**50**立方米橇装式加油设备，不能保证油罐及橇装式加油站的本质安全，油罐没有经过防爆性能检测，**曾被天津市安监局发通知暂停使用、待进一步论证后再确定是否使用。**
- 当年**3月5日**，陕西省安监局向陕西高速延长石油公司发函，要求其提供北京优孚尔公司橇装式加油装置油罐的防火防爆性能和自动灭火器的性能通过具有资质的国家有关机构的测试认证资料。
- 北京优孚尔公司与当年**3月19日**即向上海市卢湾区人民法院起诉，指控上海华篷公司损害其商誉，对其构成商业诋毁。

一审判决

- 卢湾区法院一审认为，案件的争议焦点主要有两个：一是被告是否存在捏造虚伪事实；二是被告是否散布虚伪事实。
- 一审法院认为，**上海华篷公司的举报结论都是推论性的**，被告向职权部门反映情况并没有进行举证。此外，上海华篷公司仅依据天津市安监局关于暂停使用北京优孚尔公司的商品、待进一步论证后再确定是否使用的通知，得出北京优孚尔公司产品有不合格验收记录的结论，损害了北京优孚尔公司的商品信誉商业声誉。
- 就是否存在散布行为上，一审法院认为，上海华篷公司借助一个更有影响力和公信力的主体——陕西省安监局，**向消费者间接传达了“优孚尔橇装式加油装置不能保证油罐本质安全”，“没有经过防爆性能检测”，存在“验收不合格记录”等不实信息。**
- **2010年10月20日**，上海市卢湾区法院作出一审判决，认定上海华篷公司**构成商业诋毁**。

二审判决（1）

- 二审法院认为，是否捏造虚伪事实主要依据是“情况反映”，而判断“情况反映”的内容是否属于虚伪应当从两个方面进行考量：一是内容本身与客观事实是否大部分相符；二是信息的制造者得出结论的依据是否充分以及论证过程的妥当性。
- 本案中,优孚尔公司提供的证据只能说明其产品耐火性能合格,并不能说明防爆性能合格。上海华篷公司情况反映中所涉及大部分内容都是事实。上海华篷公司依据收集到的材料和自身专业知识提出的“非本质安全”等一些推论性观点,在北京优孚尔公司未提供防爆性能测试的情况下,不能认为该产品已经符合相关技术规范。因此上述观点存在一定的合理性。

二审判决（2）

- 此外，鉴于橇装式加油装置的特殊性，上海华篷公司也不太可能通过购买方式取得实物后交有关部门进行检测。因此，上海华篷情况反映内容大部分属实，不构成捏造虚伪事实。因此也就不存在散布虚伪事实的行为。
- 上海市一中院作出二审判决，认定上海华篷公司向陕西省安监局进行情况反映，不构成商业诋毁行为。

商业诋毁必须针对特定的主体

- 指名点姓 肯定属于
- 含沙射影 看情况，如果足够精确能让人明显知晓那么属于，否则不属于
- 针对产品类别不针对特定企业的呢？
- 1、针对一个行业、一般的人和事，即使会造成公众对某个行业的信任度普遍下降，也不构成诋毁
- 2、表面上没有特定对象，在实际上影响了特定竞争对手的交易机会。
- 3、区分是第三方的诋毁还是竞争者的诋毁？

怀柔栗日本拒绝进口

针对特定主体

— 案例：汇丽公司诉森林王公司案

- 汇丽公司经营实木地板，森林王经营复合地板
- 汇丽声称：复合地板是工业垃圾，质量低劣而且甲醛含量高，是尼古丁危害的五倍等等
- 法院认为：经营者在发布侵权广告的过程中，即使没有针对某一个特定经营者，而是笼统的泛指某一类商品，作为受侵害的该类商品的经营者有权提起不正当竞争之诉。

滥发侵权警告函

- 原则上属于自力救济——具有合法性
- 主要发生于知识产权领域
- 1、知识产权客体的无形性，侵权处于持续状态
- 2、知识产权具有权利的模糊性和相对性
- 知识产权不侵权之诉 收到侵权警告函后，可以要求对方三个月内起诉，如果对方不起诉，可以向法院起诉要求明确不侵权
- 有利于明晰权利边界
- 3、促进纠纷的协商解决、节约资源
- 4、作为被告故意侵权的证据

滥发知识产权警告函

- 同时，知识产权警告函亦具有竞争属性
- 如果将警告函进行扩散或者不适当扩大发放范围，以致破坏竞争对手的竞争优势时，就可能成为不正当竞争行为。

- 是否具有正当目的？
- 是否仅限于侵权主体和处理机关？
- 内容是否严谨和准确？
- 发送的方式（比如对方正在上市）

滥发知识产权警告函

序号	涉诉公取(被告 VS.原告)	诉讼案由	涉案金额	诉讼时间	所处阶段	后续进展
1	安翰科技 VS.金山科技	专利侵权	5000 万	2019.5	上市前	应对不力，终止审核
2	白山科技 VS.网道科技	专利侵权	1.5 亿	2019.5	上市前	专利实力相对较弱，中止审核
3	光峰科技 VS.台达电子	专利侵权	4843 万元	2019.7	已上市	第一时间有效应对，股价大幅上涨
4	晶丰明源 VS.砂力杰	专利侵权	400 万元	2019.7	上市前	有效应对，成功上市
5	传音控股 VS.华为	著作权侵权	2000 万元	2019.9	已上市	无有效应对，股价大幅下挫
6	长阳科技 VS.日本东丽	专利侵权	2660 万	2019.11	已上市	尚未有效应对，股价大幅下挫

发送的意图和目的

- 是否具有正当目的

都不具备正当目的

“A公司生产销售同类给煤机备品备件，涉嫌侵犯我公司技术秘密，我司已向上海市第一中级人民法院提起起诉.....根据A公司公布的业绩显示，贵公司购买使用了A公司涉嫌侵权的给煤机备件。如有举证需要，请贵公司协助法庭调查取证。”

A、B两公司系国内最大的竞争对手。A公司在起诉B公司侵犯商业秘密侵权后，将未决案件的起诉书上传到网上，且给城市招标相关主管部门写信，投诉B公司取得的建设项目不符合当地招标规定，有商业秘密侵权行为。

发送的对象

- 1、涉嫌侵权人
- 正当维权
- 2、涉嫌侵权人的上下游客户或继发侵权人
- 市场竞争目的
- 3、政府主管机关、行业协会
- 投诉：区分正当反应问题和不正当获得交易机会
- 4、公众——广而告之
- 市场竞争目的

继发：比如使用了侵权的专利产品的相关方

措辞的严谨性和内容的准确性

- 1、总体要求：
- 权利人应当充分披露权利依据及对方侵权的详细信息，如涉及知识产权及其具体权利范围、涉嫌侵权的具体行为和理由。
- 2、区分对象：
- 向竞争对手的上下游客户发送侵权警告需要承担更高的注意义务，不得使用含糊其辞、似是而非的言辞或将未确定的事实作为确定的事实。

发送侵权警告的方式

- 总体原则：
- 发送的范围越广，注意义务越高
- 原因：受众越广，其中能够分辨事实真相的人的概率就越低，对侵权人的影响越大
- 发送的时机：
- 如上市时、招标时等

警告函错误与商业诋毁

- 警告函错误是否一定构成商业诋毁？
- 利益平衡：
- 合法维权的需求与保护接收方的合法权益
- 主要判断依据：
- 是否有编造事实剥夺对方交易机会的意图
- *理邦公司诉迈瑞公司商业诋毁纠纷 迈瑞公司给理邦公司的客户发警告函，说对方侵权
- 迈瑞公司在专利侵权诉讼中撤回了23件中12件诉请 在专利诉讼中，撤回诉请属于正常情况，因为专利申请的过程中可能存在错误、重复申请等问题，故不存在编造事实的情况

通知错误与商业诋毁

在曼波鱼诉康贝婴不正当竞争纠纷案中，被告康贝婴公司向淘宝投诉29家销售原告生产的“曼波鱼婴儿游泳池”产品的网店侵犯其专利权，并提交了权利证书、权利人身份材料、网店地址以及责任担保声明。淘宝公司在接到侵权投诉后删除了被投诉的链接，并将投诉转达原告。原告收到投诉后便发出反投诉通知，淘宝公司在审核后恢复了被删除的产品链接。原告曼波鱼公司诉称：其与康贝厂均系经营婴儿游泳池等婴儿产品的企业，且均设有在线销售，康贝厂系出于不正当竞争的目的，为打压竞争对手，故意捏造该公司的虚假侵权事实，并恶意向淘宝公司进行投诉，导致其遭受经济损失以及商誉贬损，故构成不正当竞争。

通知错误与商业诋毁

- 一审法院认为被告构成不正当竞争，理由如下：被告购买过原告的产品，并进行过技术比对，显然知道或应当知道原告的产品不侵权，但依然向淘宝公司发送侵权投诉，导致原告蒙受损失，被告的行为已超过正常维权的范畴，违背了诚实信用原则和公认的商业道德，损害了原告的商业信誉。
- 二审法院则认为被告不构成不正当竞争，理由如下：现有证据不足以证明被告明知原告产品不侵权而发出投诉通知，也不能证明被告有损害原告商誉的主观故意；此外，若要求侵权投诉最终得到司法的肯认才能使通知人免于承担赔偿责任，则会对正常的投诉行为产生不良影响。
- 参见浙江省高级人民法院（2010）浙知终字第196号民事判决书。

通知错误与商业诋毁

- 法院可综合考量如下因素：发明专利才需要进行实质性审查
- 1) 通知人是否虚构权利基础，如将广泛公知的技术申请为专利，
- 袁利中利用实用新型专利申请不进行实质性审查的制度安排，将公知的国家标准申请为专利，并企图通过诉讼排斥竞争对手。
- 2) 将“破洞”、“吉祥物”和“呼啦圈”等描述性词汇注册为商标；
- 3) 通知人是否囤积大量商标；
- 4) 通知人权利的稳定性，如明知权利缺乏稳定性，却大量发出侵权通知；
- 许赞有的外观设计权的有效性广受挑战，因而其应当意识到自己的外观设计权有效性存疑，但其仍然申请采取财产保全、停止有关行为等给雪强公司造成直接损失的措施，应当属于申请错误，构成侵权。财产保全：原告发现被告有可能出现转移资产的行为，可以申请财产保全，冻结对方的账户
- 5) 通知是否针对明显不侵权的产品；
- 6) 通知发出的时间、方式和数量，如在购物节前夕广发侵权通知、以不合理地方式重复发出通知
- 在收到反通知后并不起诉或向行政机关投诉，而是多次重复发出相同或实质上相似的侵权通知；虽然在收到反通知后起诉或向行政机关投诉，但后来又撤诉，并再次向电商平台发出相同或实质上相似的侵权通知。

商业诋毁的法律要件（4）

- 行为后果
 - 是否具有商誉？
 - 商誉具有地域性：
 - 是否具有经营活动
 - 是否具有有一定数量的消费者知道该经营者
 - 是否受到损失？
 - 被诋毁者的商业形象或商品形象方面的社会评价降低或有降低的可能性；
 - 是否造成实际的经济损失并不是认定商业诋毁行为的必要条件。

商业诋毁与虚假宣传的关系（1）

- 联系

- 本质：经营者通过传播某种不真实的信息来影响消费者的购买决策，从而获取市场优势和经济利益的不正当竞争行为。
- 商业诋毁行为往往先构成虚假宣传行为，虚假宣传通过抬高自己商品声誉，进一步构成对特定竞争对手的商业诋毁。
- 商业诋毁行为在学理上可以认为是虚假宣传的特别行为。

商业诋毁与虚假宣传的关系（2）

- 区别

- 行为针对的对象不同：

- 虚假宣传行为一般是没有明确针对对象的
 - 商业诋毁行为通常是有特定的针对对象的

- 宣传内容内容涉及的范围不同：

- 虚假宣传行为可以只涉及自己的商品或服务；
 - 商业诋毁行为除了涉及自己的商品或服务外，还需要涉及其他经营者的商品或者服务。

商业诋毁与虚假宣传的关系（3）

- 案例：王老吉诉加多宝虚假宣传
- 加多宝在宣传其红罐凉茶时使用“王老吉改名加多宝”、“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”、“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝，怕上火更多人喝加多宝，配方正宗当然更多人喝”的广告语。
- 虚假宣传：拔高自己
- 商业诋毁：诋毁他人



福清大闽公司诉南海岸公司

商业诋毁行为的举证困难

- 商业诋毁证据的特征：
 - **隐蔽性**。诋毁内容是公开的，但诋毁人一般不公开承认是自己所为。
 - **难印证性**。由于诋毁内容一般都是得到过多人的传播，所以即使发现其单位或个人实施了诋毁行为，也难以对此分清诋毁信息的原始制造人和中间环节传播人。

新媒体的角色、广告软文

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>